

1500645-51.2022.8.26.0366

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME PINHO RIBEIRO

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... para a prática do delito de tráfico de drogas, prestando auxílio material ao adolescente Lucas Gabriel Alves Diniz, que trazia consigo, para fins de tráfico, 664 porções de cocaína, 152 pedras de crack, 25 frascos de lança perfume, 29 porções de haxixe e 131 porções de maconha”.

Audiência de Custódia realizada em 14 de setembro de 2022, momento em que homologada a prisão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá-SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500645-51.2022.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500645-51.2022.8.26.0366

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2250601/2022 - DISE- DEL.SEC.ITANHAEM, 27402174 - DISE- DEL.SEC.ITANHAEM, 2250601 - DISE- DEL.SEC.ITANHAEM

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

ADEMILTON ALVES OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME PINHO RIBEIRO

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de ADEMILTON ALVES OLIVEIRA, já qualificado nos autos, como incurso no topo do artigo 33 c/c art. artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal afirmando que “no dia 13 de setembro de 2022, por volta das 19h29, na Rua Sete de Setembro, n. 1446, Vila Atlântica, nesta cidade e comarca de Mongaguá, o acusado concorreu para a prática do delito de tráfico de drogas, prestando auxílio material ao adolescente Lucas Gabriel Alves Diniz, que trazia consigo, para fins de tráfico, 664 porções de cocaína, 152 pedras de crack, 25 frascos de lança perfume, 29 porções de haxixe e 131 porções de maconha”.

Audiência de Custódia realizada em 14 de setembro de 2022, momento em que homologada a prisão em flagrante do acusado, bem como convertida em preventiva e recebida a denúncia (fls. 61/63).

Resposta à acusação apresentada a fls. 69/71.

Decisão de fls. 95/96 rejeitou a defesa prévia e ratificou o recebimento da denúncia. Na mesma oportunidade, o pedido de instauração do incidente de dependência química foi indeferido.

Audiência de instrução e julgamento realizada em 22 de novembro de 2022, momento em que ouvidas duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Foi determinada a continuação da audiência em razão de uma testemunha faltante (fls. 128/129).

O Ministério Público apresentou alegações finais oralmente, requerendo a procedência da pretensão punitiva, tendo em vista a presença de materialidade e provas suficientes de autoria.

A Defesa Técnica do réu, também oralmente, aduziu, em síntese, que não há provas suficientes para embasar o pleito condenatório pugnando por sua absolvição ou, seja aplicada a causa de diminuição contida no art. 33, parágrafo 3º, Lei n. 11.343/06.

É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada na qual veiculada imputação da prática do crime descrito no artigo 33 c/c art. artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal.

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/12), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 13/14), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 15/16), laudo toxicológico definitivo (fls. 79/82), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, conforme ata e mídia. A autoria também é certa.

A testemunha Carlos Henrique S. da Horta, policial civil, ouvido em Juízo, disse que (a) o local é conhecido como ponto de venda de drogas, tendo os policiais se dirigido até lá para averiguação do responsável pela venda dos entorpecentes, (b) o indivíduo responsável pela guarda da sacola também era o vendedor, (c) Ademilton era o "campana", (d) o acusado estava a cerca de 03 metros do adolescente que portava a sacola com as drogas, (e) inicialmente, passaram por um outro "campana", que tentou alertar ao réu sobre a presença dos policiais no local, (f) Ademilton era o responsável pela segurança do local, bem como pela triagem dos compradores, (g) informalmente, o acusado disse aos policiais, no momento da prisão, que era usuário de drogas e estava trabalhando para alimentar seu vício.

A testemunha Henrique Campana de Almeida, ouvido em Juízo, disse que (a) estava na biqueira para comprar maconha, quando os policiais chegaram, (b) ele e outros sujeitos que estavam no local foram levados presos até a delegacia, (c) não sabe dizer se o acusado estava no local dos fatos, (d) quando da chegada dos agentes, já havia adquirido a droga.

A testemunha Luciano Cesar da Silva, policial civil, ouvido em Juízo, disse que (a) o local é conhecido como ponto de tráfico de difícil acesso, pois há uma área de

mata nativa e para se aproximar, somente com carro descaracterizado, (b) identificaram um sujeito com uma mochila, sendo abordado por transeuntes, (c) os policiais fizeram a aproximação a pé, (d) Lucas estava vendendo a droga, e o acusado estava exercendo a função de olheiro, (e) a droga fica na mochila com o adolescente, uma grande quantidade de entorpecente, (f) Ademilton estava a dois ou três passos do vendedor, realizando uma espécie de triagem.

O acusado Ademilton Alves Oliveira, em solo policial (fls. 06), disse que (a) estava trabalhando de "olheiro" na "Biqueira da Sete", quando os policiais civis o abordaram, juntamente com um usuário e o "Sacola", (b) ganha R\$50,00 para exercer a função de "olheiro", mas gasta quase tudo com seu vício em crack. Em Juízo, ao ser interrogado, alegou que (c) estava trabalhando de campana naquele dia, pois estava devendo dinheiro para traficantes, motivo pelo qual exerceu a atividade ilícita naquele dia.

Os depoimentos da testemunha ouvida em juízo foi uniforme e coerente, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Ademais, o próprio acusado confessou a prática delitiva.

Quanto à tipificação do delito praticado pelo acusado, entendo cabível a desclassificação para a capitulação nos termos do art. 37 da Lei n. 11.343/06, em observância ao previsto no art. 383 do Código de Processo Penal.

Embora a função de "olheiro" do tráfico tenha inegável relação de participação no crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, o Poder Legislativo, no âmbito de suas funções constitucionais primárias, entendeu por bem estabelecer crime autônomo à conduta em apreço, consistente em "colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinada à prática de qualquer dos crimes previstos no art. 33, caput, e parágrafo 1º, e art. 34 desta Lei [de Drogas]". Trata-se, portanto, de delito acessório.

Não houvesse positivado o crime em apreço, poder-se-ia falar em aplicação subsidiária do delito principal em cumulação com a figura da participação, previsto no art. 29 do Código Penal. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO RECONHECIDA. OLHEIRO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INERENTE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça a orientação no sentido de que se mostra indispensável, para fins de configuração do crime de associação para o tráfico, a evidência do vínculo estável e permanente dos acusados com outros indivíduos, o que, consoante as premissas estabelecidas no acórdão recorrido, não ocorreu, razão pela qual indevida a condenação, não havendo falar em exame aprofundado da prova.

2. Admite-se a desclassificação para a capitulação jurídica nos termos do art. 37 da Lei de Drogas, à conduta de "olheiro", quando não demonstrada na origem a prática mediante contribuição estável e permanente aos destinatários das informações que possibilitariam o cometimento do tráfico de drogas, já que a referida figura típica pressupõe o vínculo esporádico e eventual.

(...)

5. Agravo regimental improvido."

(STJ. SEXTA TURMA. AgRg no HC 632550/RJ, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. em 09 de março de 2021, destacado).

Portanto, entendo que o réu incorreu na prática do delito positivado no art. 37 da Lei n. 11.346/06, que tem como pena "reclusão, de 02 a 06 anos, e pagamento de 300 a 700 dias-multa". Passo a dosar a pena.

Quanto às causas modificativas da pena, constato que o réu é primário e de bons antecedentes (fls. 51/53). O delito foi praticado envolvendo o adolescente L.G.A.D. nascido em 08 de fevereiro de 2005 (fls. 05), incidindo a causa de aumento da pena previsto no art. 40, VI, Lei de Drogas.

Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias judiciais, anoto que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, são preponderantes nesta fase a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Constatado que a quantidade e variedade da droga apreendida são consideráveis, tratando-se de 664 porções de cocaína, 152 pedras de crack, 25 frascos de lança perfume, 29 porções de haxixe e 131 porções de maconha (fls. 79/82). Portanto, fixo a pena base em 03 anos de reclusão, além do pagamento de 400 dias-multa.

Segunda etapa. Não há circunstâncias agravantes. O réu confessou a prática delitativa, fazendo incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d", CP. Portanto, fica estabelecida a pena intermediária no patamar de 02 anos e 06 meses de reclusão, além do pagamento de 333 dias-multa.

Terceira etapa. Não há causas de diminuição de pena a considerar. Está presente a causa de aumento positivada no art. 40, VI, Lei de Drogas, com intervalo de 1/6 a 2/3 da pena. Considerando que se constatou a presença de apenas um adolescente na prática da traficância, com 17 anos à época dos fatos, entendo cabível o aumento no mínimo legal. Portanto, fica estabelecida a pena em definitivo no patamar de 02 anos e 11 meses de reclusão, além do pagamento de 388 dias-multa.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Regime de cumprimento de pena e o tempo de prisão provisória. O sentenciado é primário, as circunstâncias judiciais foram favoráveis e a pena final ficou abaixo de 04 (quatro) anos. Bem por isso, com base no art. 33, §2º, "c", do CP, estabeleço o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena. Eventual tempo de prisão cautelar não interfere na fixação do regime prisional - art. 387, §2º, do CPP.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A pena privativa de liberdade foi fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; o réu não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais revelam que a sua substituição por pena restritiva de direitos é suficiente.

Portanto, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 2 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal, consistentes na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, à razão de uma hora por dia de condenação, e na PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.

A prestação pecuniária consistirá no pagamento de 01 (um) salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada pelo Juízo da Execução Criminal (artigo 45, §1º, do Código Penal).

A prestação de serviços à comunidade, aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade, consistirá na atribuição de tarefas gratuitas ao acusado a serem realizadas em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres. Devem ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho (artigo 46, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Suspensão condicional da pena. Substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fica prejudicado o exame acerca do cabimento da suspensão condicional da pena – art. 77, III, do CP.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDEAR ADEMILTON ALVES OLIVEIRA à pena de reclusão, pelo prazo de 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 333 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no topo do artigo 37 da Lei 11.343/06.

Substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Verifica-se que a fixação do regime inicial aberto é incompatível com a manutenção da prisão cautelar, cuja revogação se impõe. Ademais, houve suspensão condicional da pena privativa de liberdade, fato que não se compatibiliza com a manutenção da prisão preventiva. Por tais razões, revoga-se a prisão preventiva determinada no curso do processo.

Expeça-se alvará de soltura clausulado, imediatamente.

Não obstante, expeça-se guia provisória de execução penal, em atenção ao que determina a Súmula 716/STF, a fim de que sejam implementadas as condições do regime ora imposto (STF, HC 180957, Segunda Turma, DJe 13.05.2020, RHC 166279/SP, Segunda Turma, DJe 2.2.2020; HC 123267, Primeira Turma, DJe 02.02.2015; STF, HC 118528, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 14.02.2014), tal como admitido também pelo STJ (RHC 12.561/GO, Quinta Turma, DJe 29.06.2020, RHC 75.051/MG, Sexta Turma, DJe 16.12.2016), salvo se da unificação de penas resultar a imposição de regime mais gravoso pelo Juízo da execução penal (LEP, art. 111, parágrafo único).

Quanto à droga apreendida, deve ser promovida a destruição das amostras eventualmente acauteladas, caso ainda não tenha sido realizada, na forma do art. 72 da Lei n. 11.343/06.

Quanto à multa, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, com o trânsito em julgado, expeça-se certidão da sentença, abrindo-se vista ao Ministério Público, nos termos do art. 480, NSCGJ/SP.

Custas pelo réu (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogado dativo e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Partes intimadas em audiência.

Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Mongaguá, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA